

1500389-77.2021.8.26.0129

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE ALFREDO DE ANDRADE FILHO

Comarca: Casa Branca

Foro: Foro de Casa Branca

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de consumo de drogas para uso próprio; subsidiariamente, solicitou o a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da menoridade relativa e do tráfico privilegiado (fls. 176/182).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, em que pese a audiência de instrução não tenha sido presidida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Casa Branca

Foro de Casa Branca

1ª Vara

Praça Ministro Costa Manso, 78, Casa Branca-SP - cep 13700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500389-77.2021.8.26.0129 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500389-77.2021.8.26.0129

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2168962/2021 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 18648112 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 543/21/200 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2168962 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 543/21/200 - DEL.INV.GER.

CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL FRANK CINCLAIR AMORIM DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE ALFREDO DE ANDRADE FILHO

Vistos.

GABRIEL FRANK CINCLAIR AMORIM DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, porque, no dia 22 de junho de 2021, por volta de 19h20min, na Rua Maria Regina B. Carvalho, 89, Bairro Conjunto Habitacional Waldemar Pereira, na cidade e Comarca de Casa Branca, trazia consigo e guardava, para fins de consumo de terceiros, 04 (quatro) invólucros plásticos tipo "eppendorf", contendo Cocaína, pesando 2,1g (dois gramas e um decigrama), droga esta causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi regularmente notificado (fl. 116) e apresentou defesa preliminar (fl. 134).

Recebida a denúncia no dia 07 de outubro de 2021. (fls. 139/141).

Em audiência de instrução, foram inquiridas testemunhas arroladas pelo Ministério Público e, como o réu não compareceu ao ato, não apresentando justificativa para tanto, foi decretada sua revelia (fls. 160/161).

Em memoriais escritos, o Ministério Público postulou a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (fls. 166/171), ao passo que a Defesa solicitou a absolvição do acusado por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de consumo de drogas para uso próprio; subsidiariamente, solicitou o a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da menoridade relativa e do tráfico privilegiado (fls. 176/182).

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, em que pese a audiência de instrução não tenha sido presidida por este julgador, quando os autos vieram conclusos para sentença já havia cessado a designação do D. Magistrado que presidiu a instrução, razão pela qual passo a sentenciar o feito.

Assim, o fato de a sentença ser proferida por julgador que não conduziu a instrução não enseja a nulidade do processo. Isso porque o art. 399, §2º, do Código de Processo Penal traz regra que deverá ser observada sempre que possível, mas que encontra exceções, dentre as quais o afastamento regulamentar do Magistrado que presidiu a instrução, caso dos autos.

Nesse sentido:

“O princípio da identidade física do juiz pode ser excepcionado nos casos de convocação, licença, promoção, férias, ou outro motivo legal que impeça o (a) Magistrado (a) que presidiu a instrução sentenciar o feito. Precedentes. 2. No caso, a Magistrada que presidiu a audiência estava em gozo de férias regulamentares. Assim, a sentença condenatória proferida por outro Membro do Poder Judiciário é válida.” (RHC 111.670/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 13/06/2019).

Demais disso, o processo penal, em tema de nulidades, é regido pela máxima *pas de nullité sans grief*, consagrado pelo legislador no art. 563 do CPP e pela jurisprudência na Súmula nº 523/STF, ou seja, não deve ser declarada nulidade quando não resultar prejuízo comprovado:

“A jurisprudência desta Corte Superior entende que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto e pode ser mitigado. Em se tratando de nulidade relativa, necessária para o seu reconhecimento a demonstração de prejuízo pela parte” (STJ, AgRg no AREsp 1013335/DF, Sexta Turma, Rel Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 6/6/2018).

Feito tal esclarecimento, trata-se de ação penal pública incondicionada, cujo processo, em trâmite pelo rito especial, apura a materialidade e autoria do episódio criminoso narrado na denúncia.

Finda a instrução, por mais respeitáveis que possam ser os argumentos exculpatórios, temos que a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade foi comprovada pelos elementos informativos que instruem os autos, em especial, pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01 e seguintes), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 14), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 15), pelo laudo pericial de fls. 77/79, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Autoria incontestável, conforme se comprovou pela robusta prova oral.

As testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram ouvidas sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, o Policial Militar Danilo Aparecido Monteiro Felix da Silva relatou, em resumo, que, no dia dos fatos, efetuavam patrulhamento, quando receberam informações anônimas de um morador do "Bairro Andorinhas", dando conta que o acusado, que trajava calça e blusa preta, estava promovendo tráfico de drogas naquele bairro. Referido morador informou, ademais, que o réu escondia a droga em um "padrão de água". Diante dessas informações, dirigiram-se ao local indicado, onde visualizaram o acusado, trajando as vestimentas idênticas as informadas na denúncia anônima. Em seguida, realizaram abordagem. Durante a busca pessoal, encontraram uma porção de cocaína e o valor de R\$ 30,00. Questionado, o réu alegou ser usuário. Ato contínuo, realizaram buscas no local e, em uma "relógio de água", foram encontradas mais três porções de cocaína, iguais as localizadas com o acusado. Em razão disso, efetuaram a prisão em flagrante. Esclareceu que foi necessário uso de algemas, porque o réu dava a entender que queria empreender fuga; que a denúncia anônima também falava o nome do réu; que o denunciante era morador do bairro e pediu anonimato, por medo de represálias; que já tinha denúncias de pessoas diferentes, no sentido de que o réu traficava no local dos fatos; que, em relação às drogas encontradas no "relógio de água", o réu nada disse; e que o acusado não aparentava ter ingerido drogas.

O Policial Militar Cristiano Donizete da Silva Antoniali relatou, em síntese, que, no dia dos fatos, durante patrulhamento no "Jardim Andorinhas", um morador de tal bairro informou-lhes que estava ocorrendo tráfico de drogas no local. O denunciante passou as características do réu e disse que as roupas deste eram pretas, bem como disse que onde o réu guardava as drogas. Diante disso, dirigiram-se ao local indica, que é conhecido por ponto de tráfico, e visualizaram o réu, que foi abordado. Em poder do acusado, foram encontrados um pino de cocaína e a quantia de R\$ 30,00. Realizada varredura no local, encontraram mais três eppendorfs contendo cocaína. Esclareceu que a denúncia mencionou o nome do réu; e que já havia denúncias contra o acusado.

O acusado, em seus esclarecimentos prestados em solo policial, afirmou que é usuário de drogas desde os 18 (dezoito) anos de idade e que a encontrada era para seu consumo; que a quantia em dinheiro encontrada seria utilizada para adquirir mais drogas; que estava no local dos fatos para adquirir substância entorpecentes; que não possui qualquer envolvimento com a droga encontrada no padrão de água; e que é trabalhador e que convive com o vício (fl. 08).

Ante a revelia decretada, o réu não foi interrogado em pretório, sob a égide processual.

Diante desse contexto fático-probatório, tem-se o seguinte cenário: a) antes dos fatos, havia denúncias anônimas contra o acusado, no sentido de que ele estava traficando drogas; b) no dia do ocorrido, os Policiais Militares, ouvidos sob a égide processual, realizavam patrulhamento, quando um morador do "Bairro Andorinhas" - local conhecido como ponto de tráfico de drogas - informou-lhes que o réu estava comercializando drogas no referido bairro; o denunciante, além de informar o nome do réu, repassou as características, as vestimentas e indicou o

local onde as drogas eram guardadas; c) diante disso, os agentes públicos dirigiram-se ao local indicado, momento em que visualizaram o réu, o qual possuía as mesmas características e trajava vestimentas idênticas às informadas pelo denunciante; d) realizada abordagem, em busca pessoal, encontraram uma porção de cocaína e a quantia de R\$ 30,00; e) em seguida, efetuaram buscas e encontraram mais três porções de cocaína, onde o denunciante tinha indicado como local em que as drogas eram guardadas (em um “relógio de água”); diante disso, o réu foi preso em flagrante.

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto e sopesadas entre si, não deixam dúvidas acerca da ocorrência da narcotraficância, sendo certo que, realmente, as substâncias entorpecentes localizadas se destinavam ao comércio ilícito.

De mais a mais, em que pese a negativa do acusado, merecem prevalecer os depoimentos dos policiais na fase inquisitorial e em Juízo, que narraram os fatos com riqueza de detalhes e de forma coerente e uníssona.

Nenhum motivo para falsa incriminação foi alegado e os policiais, ao prestarem depoimento em juízo, além de firmes e coerentes, fizeram relatos verossímeis, nada existindo que possa infirmar a lisura de suas palavras.

Sobre o testemunho dos policiais, confira-se:

“Os testemunhos de policiais, destacados para a realização da repressão criminal, devem ser aceitos quando se prestam a dar contas da tarefa realizada, inexistindo motivo para que sejam considerados tendenciosos. Podem ser rechaçados somente quando comprovado que houve falseamento da verdade ou que estão em desconformidade com o restante da prova, como ocorre com todo tipo de prova. Nesse teor, também, o v. aresto do STF no HC nº 73.518/SP, rel. MIN. CELSO DE MELLO” (TACRIM, Apelação nº 1327851/4, 12ª Câmara, Rel. Des. LUÍS GANZERLA, j. 7-4-2003, v.u.).

No mesmo sentido, de acordo com reiterada jurisprudência, “nos chamados ‘crimes de tóxico’ (Lei nº 6.368/76) que tem início com flagrante lavrado por policiais, a palavra destes tem força probante salvo comprovação em contrário” (TJMT, AC nº 255/79, Rel. Des. MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, RT 541/408).

Realmente, “não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas” (TJRJ, AC, Rel. Des. SYNÉSIO DE AQUINO, RDTJRJ 7/287).

Acrescente-se que, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

É dizer, para a configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/06, crime de ação múltipla ou de conteúdo variável, é suficiente que o agente incida em apenas uma das condutas nucleares – trazer, guardar, ter em depósito, etc. – pois a consumação não exige qualquer outro resultado, como a venda ou a efetiva entrega da coisa, bastando a posse da droga.

Nesse sentido, têm-se exemplo da jurisprudência:

“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes dos agentes” (RT 584/347, Rel. Desembargador

GERALDO GOMES).

De fato, as assertivas dos policiais, no tocante ao fato principal, mostraram-se harmônicas, firmes e condizentes com todos os elementos sensíveis da infração e subsídios de convicção coligidos aos autos. Não foram abaladas por nenhum fator concreto e, bem por isso, devem ser prestigiadas.

As versões defensivas, por seu turno, não merecem, com a devida vênia, valor probatório superior ao dos servidores públicos, que não tinham relação de afeto ou ódio com o acusado e estavam comprometidos com a cabal apuração dos fatos e com a defesa do interesse da sociedade.

Não há nos autos motivo algum para imaginar que os testigos incriminatórios tenham sido fruto da ação de pessoas que agiram de forma leviana tão só para prejudicar o acusado gratuitamente.

Assim, não há falar em insuficiência probatória, já que as provas, ao contrário, são suficientes à condenação, sendo de rigor a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

De outra parte, em que pese a alegação de que as drogas eram destinadas ao seu consumo próprio, nada se comprovou a esse respeito. A propósito, a partir das circunstâncias acima indicadas, nota-se que referida tese defensiva restou isolada das demais provas produzidas nos autos.

Logo, a alegação de ser mero usuário, o que, repiso, não foi comprovado nos autos, cai por terra diante da fragilidade das alegações defensivas.

Cedico que, "Nenhuma incompatibilidade existe entre o tráfico de entorpecente e o vício. Ao contrário. Em regra, vivem associados" (RT 411/104, Rel. Desembargador HUMBERTO DA NOVA).

Em suma, comprovadas materialidade e autoria do delito descrito na denúncia, e elidida a versão exculpatória, a condenação do acusado é medida de rigor.

Apurada a responsabilidade penal, passo à dosimetria da pena, segundo o critério previsto no art. 42 da Lei de Drogas e nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na dosimetria da sanção penal, devem ser levadas em consideração, na primeira fase, as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal. Trata-se de réu primário (fls. 27/30). Assim, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão, além de 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a considerar. Respeitado o entendimento do D. Defensor, não há que se falar em menoridade relativa, uma vez que o réu não era menor de 21 anos na data dos fatos, pois nasceu em 29 de fevereiro de 2000 (fl. 08) e o crime foi cometido no dia 22 de junho de 2021.

Na terceira fase da dosagem, não restou configurada a causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. A congérie probatória evidencia, à sociedade, que o réu se dedicava sistematicamente a atividades criminosas com habitualidade. O redutor em comento é destinado ao tráfico episódico, ocasional, eventual ou isolado. Não é o caso: o acusado foi preso em flagrante após informações em seu desfavor, de pessoas diferentes, no sentido de que estava traficando drogas no local dos fatos. Aliás, o denunciante anônimo informou que riqueza de detalhes o local que o tráfico ocorria e onde as drogas eram guardadas. Logo, não pode ser beneficiado com a causa de diminuição de pena.

O valor unitário da sanção pecuniária cumulativa, ante as condições financeiras do acusado, é fixado no mínimo de 1/30 do salário mínimo nacional, vigente na data do fato, atualizado desde então.

A despeito da primariedade do agente, o delito é apenado com reclusão (CPP, art. 313, I), além do seu caráter hediondo, a justificar modalidade mais severa e maior rigor penitenciário para início de desconto da segregativa. Ademais, restou comprovado o envolvimento não ocasional do réu no comércio espúrio de tóxicos. Portanto, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, por ser o único condizente com o princípio da suficiência dada a gravidade do delito, que perturba a ordem social, alicia e corrompe crianças e adolescentes, aniquila a força produtiva de usuários e viciados e fomenta a criminalidade, produzindo efeitos deletérios a toda coletividade, a exigir tratamento mais rigoroso sob pena de a reprimenda não alcançar, a contento, sua finalidade preventiva e retributiva. Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 12.736/2012, porque o regime inicial não foi fixado com base na quantidade de pena aplicada.

Pelas mesmas razões, desaconselhável, no caso específico dos autos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal) ou ainda a concessão de sursis (art. 77 do Código Penal).

As demais alegações não comportam outras considerações ou digressões, por haver incompatibilidade lógica com o quanto já mencionado.

Como é sabido, o órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações ou se referir, um a um, a todos os seus argumentos.

Com efeito, “o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão-somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão” (STF, HC nº 82.746-SP).

No mesmo sentido:

“Não se tem como omissa a sentença condenatória que, embora não se referindo, expressamente, à tese da defesa, fundamenta a condenação com base nos elementos probatórios reputados válidos para caracterizar o crime narrado na denúncia e sua autoria. (...). Embora seja necessário que o Magistrado aprecie todas as teses ventiladas pela defesa, torna-se despiciendo a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão condenatória, resta claro que o julgador adotou posicionamento contrário” (STJ, RHC nº 12.842-0/PR).

Assim, a soma de alegações choca-se contra os fatos verificados nos autos, e conseqüentemente, são afastados os argumentos restantes, por inaplicáveis.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu GABRIEL FRANK CINCLAIR AMORIM DE LIMA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, estes arbitrados unitariamente no mínimo legal.

Custas na forma da lei (artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea “a” da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003).

Poderá recorrer em liberdade, pois assim permaneceu no curso da instrução.

Sobre a destruição da droga apreendida, reporto-me à decisão de fl. 53.

Nos termos do artigo 91, II, "b", do Código Penal e do artigo 63 e seguintes da Lei 11.343/06, decreto o perdimento valor apreendido em favor da União, pois as circunstâncias que envolvem os fatos indicam que é fruto do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, não tendo demonstrada a origem lícita do dinheiro apreendido, ônus que lhe competia.

Transitada em julgado esta sentença: a) expeça-se guia de recolhimento definitiva; b) notifique-se o réu para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP); c) oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD); d) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da CF.

P.I.C. Dispensado o registro (Provimento CG nº 27/2016).

Casa Branca, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA